

<입문-제6장 행정행위.제2절 행정행위 내용에 따른 구분>

I. 법률행위적 행정행위

1. 의의

- 법률행위적 행정행위란 행정청이 일정한 법률효과의 발생을 의욕하는 의사표시에 의하여 국민의 권리·의무에 직접 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

2. 분류

- 행정행위의 대부분이 여기에 속하며, 다시 명령적 행정행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행정행위(특허, 대리, 인가)로 나눌 수 있다.

II. 법률행위적 행정행위-명령적 행정행위

1. 명령적 행정행위의 학설

- 명령적 행정행위의 법적 성질에 대한 학설은 크게 권력설과 법률효과설로 대별될 수 있으나, 현대 행정법에서는 행정행위의 효력이 행정청의 우월한 지위에서 발생한다는 점을 인정하면서도, 궁극적으로는 그 행위의 법률적 효과에 초점을 맞춘다. 특히, 명령적 행정행위는 법규를 집행하여 국민의 권리·의무를 규율하는 행위라는 점에서 법률효과설이 통설적 지위를 차지하며, 개별 행위의 법적 근거와 목적에 따라 성질을 구체화한다.

2. 명령적 행정행위의 의의

- 명령적 행정행위란 행정청이 법규를 근거로 하여 국민의 자유를 제한하거나 의무를 부과 또는 해제하는 법률행위적 행정행위를 말한다. 이는 행정청이 우월한 공권력의 주체로서 행하는 행위라는 특성이 있다.

3. 허가

(1) 허가의 의의

- 허가란 법률이 일반 사인에게 일반적·상대적으로 금지하고 있는 행위(부작위 의무)를 특정인에 대하여 해제하여, 적법하게 그 행위를 할 수 있도록 법률적 자유를 회복시켜 주는 행정행위이다.

(2) 허가의 성질

① 법률행위적 행정행위

- 허가는 행정청의 의사 표시에 따라 법적 효과(금지 해제)가 발생하는 법률행위적 행정행위이다.

② 원칙적 기속행위

- 허가는 법령에 정해진 요건만 충족하면 행정청이 반드시 허가해야 하는 기속행위가 원칙이다. 다만, 공익적 판단이 요구되는 특정 분야에서는 예외적으로 재량이 인정될 수 있다.

(3) 허가의 종류

① 대물적 허가

- 대상 물건이나 시설의 적합성을 심사하여 부여하는 허가(건축 허가)

② 대인적 허가

- 신청인 개인의 능력이나 자격을 심사하여 부여하는 허가(운전면허)

(4) 허가의 형식 및 상대방

① 형식

- 문서주의가 원칙이나, 법령에 특별한 규정이 없는 한 구술 또는 기타 방식으로 가능하다.

② 상대방

- 특정인에게 행하는 개별적 행정행위가 원칙이다.

(5) 허가의 대상

- 허가의 대상은 법령에 의해 금지되어 있는 행위여야 한다. 금지되어 있지 않은 행위(자유 행위)에 대해 행정청이 허가라는 명칭을 사용하더라도, 이는 법적으로 허가가 아닌 확인이나 공증 등 다른 성격의 행위로 해석된다.

(6) 허가의 기준

- 허가 기준은 법적 안정성을 위해 법령에 명확하게 규정되어야 한다. 허가 여부는 법령이 정한 공익적 기준과 신청인의 적격성을 기준으로 심사하며, 법령에 없는 사유로 허가를 거부할 수 없다.

(7) 허가의 신청

- 허가는 신청인의 신청에 의해 절차가 개시되는 것이 원칙이다. 행정청은 신청이 있는 경우 법령에 따라 심사하고 응답할 의무가 있다.

(8) 허가의 효과

- 허가의 효과는 법률적 자유의 회복이다. 즉, 허가받은 행위를 적법하게 할 수 있게 되며, 법률적 불이익(처벌)을 면할 수 있다. 허가는 제3자에게 영향을 미치지 않는다.

(9) 허가 위반의 효과

- 허가 없이 금지된 행위를 하는 경우, 그 행위는 무허가 행위로서 위법해지며, 행정벌(과태료, 징역 등)의 대상이 되거나 행정상 강제집행(이행강제금 부과, 대집행)의 대상이 될 수 있다. 다만, 사법상의 효력(매매 계약의 유효성)에는 원칙적으로 영향을 미치지 않는다.

(10) 인·허가 의제 제도

- 복수의 법령에 따라 여러 개의 허가를 받아야 하는 경우, 주된 하나의 허가 신청 및 발급만으로 나머지 관련 허가를 받은 것으로 의제(간주)하는 제도이다. 행정 절차의 간소화를 목적으로 한다.

① 처분성

- 의제된 인·허가에 대하여 별도로 다룰 수는 없고, 주된 인·허가 처분의 취소소송에서 함께 다투어야 한다.(판례)

② 거부처분

- 주된 인·허가 처분이 거부될 경우, 의제된 모든 인·허가 신청에 대한 거부도 포함된 것으로 보아 주된 인·허가 처분 거부를 다투어야 한다.

(11) 예외적 허가(승인)

- 예외적 허가는 법령상 특정 행위를 원칙적으로 절대적 금지하면서, 특정한 공익적 이유나 극히 예외적인 경우에 한하여 금지를 해제하는 행위이다.

① 성격

- 단순 허가과 달리, 공익적 심사의 범위가 넓어 행정청의 재량이 인정되는 경우가 많다.

② 쟁송

- 거부 시 단순 허가보다 재량의 일탈·남용 심사 범위가 넓어진다.

4. 하명

(1) 하명의 의의

- 하명이란 행정청이 국민에게 새로운 작위, 부작위, 급부, 수인 등의 의무를 부과하는 행정행위이다. 국민의 권리나 자유를 침해하는 침익적 행정행위의 대표적인 형태이다.

(2) 하명의 종류

① 작위 하명

- 일정한 행위를 하도록 명령(건축물 철거 명령)

② 부작위 하명

- 일정한 행위를 하지 않도록 명령(통행 금지 명령)

③ 급부 하명

- 금전 등을 국가에 납부하도록 명령(세금 부과 명령)

④ 수인 하명

- 국가의 행위를 수용하고 참도록 명령(예방접종 의무 부과)

(3) 하명의 대상 및 상대방

- 하명은 주로 특정인에게 부과되는 개별 처분의 형태를 취하나, 불특정 다수인을 대상으로 할 수도 있다. 하명의 대상은 법률에 근거하여 국민에게 의무를 부과하는 행위여야 한다.

(4) 하명의 효과 및 구제

① 효과

- 국민은 하명에 의해 새로운 공법상 의무를 부담하게 된다.

② 구제

- 하명이 위법한 경우, 국민은 취소소송을 통해 그 하명의 취소를 구할 수 있다. 하명 불이행 시 행정 강제(대집행, 강제징수)나 행정벌의 대상이 된다.

5. 면제

(1) 개념

- 면제란 법령에 의해 국민에게 부과된 기존의 의무를 행정청이 해제하여 그 의무로부터 벗어나게 하는 행정행위이다.

(2) 허가과 면제의 구별

① 기존 상태

- 허가는 일반적·상대적 금지(부작위 의무) 상태, 면제는 법령에 의한 작위, 급부 등 의무 상태이다.

② 행위 효과

- 허가는 금지 해제를 통한 자유 회복이며, 면제는 의무 해제를 통한 의무 면탈이다.

③ 예시

- 허가는 영업 허가, 운전면허이며, 면제는 병역 면제, 세금 감면이다.

Ⅲ. 법률행위적 행정행위-형성적 행정행위

1. 형성적 행정행위의 의의

- 형성적 행정행위란 행정청의 의사 표시에 의하여 국민의 공법상 권리나 법률관계를 새롭게 설정하거나, 기존의 법률관계를 변경·보충하여 법적 효력을 완성시키는 법률행위적 행정행위를 말한다. 이는 국민에게 이미 존재하는 자유를 회복시켜주는 명령적 행정행위(허가, 하명, 면제)와는 구별된다. 형성적 행정행위는 주로 특허, 대리, 인가의 형태로 나타나며, 행정청의 적극적인 의사 결정이 국민의 법률관계에 직접적인 변동을 가져온다는 특징이 있다.

2. 특허-상대방을 위한 행위

(1) 특허의 의의

- 특허란 행정청이 특정 개인에게 새로운 공법상 권리나 포괄적 법률관계를 설정해주는 행정행위를 말한다. 본래 국민에게 자유가 없는 영역이거나, 공공의 필요성이나 공익적 독점성 때문에 행정청의 특별한 설정 행위를 통해서만 비소 권리 취득할 수 있는 경우에 사용된다. 특허는 공익적 판단이 폭넓게 개입되므로 원칙적으로 재량행위로 해석된다.

(2) 특허의 종류(광의의 특허)

- 광의의 특허에는 특정인에게 새로운 공법상 권리나 지위를 설정하는 협의의 특허(공익 재단 설립 허가) 외에도, 행정 재산이나 공물의 특별 사용권을 설정하는 행위(국유림 사용 허가)와 특정 직업이나 사업을 영위할 자격을 설정하는 행위(의사 면허, 방송국 면허) 등이 포함된다.

(3) 특허의 형식 및 상대방

- 특허는 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치므로 문서로 행해지는 것이 원칙이다. 특허의 상대방은 특허를 통해 새로운 권리나 지위를 취득하는 특정인이며, 특허는 특정인에 대한 개별 처분의 성격을 가진다.

(4) 특허의 효과

- 특허는 상대방에게 법적으로 보호되는 새로운 공권을 부여하는 수익적 행정행위이다. 특허로 설정된 권리(어업권, 도로 점용 허가권)는 법적 보호를 받으며, 침해 시 행정쟁송을 통해 구제받을 수 있다.

(5) 허가·특허 비교

- 특허는 새로운 권리나 포괄적 법률관계를 설정하는 행위인 반면, 허가는 법률에 의해 일반적·상대적으로 금지된 행위에 대한 금지를 해제하여 국민의 기존 법적 자유를 회복시켜주는 행위이다. 따라서 특허는 공익적 판단이 폭넓게 개입되어 원칙적으로 재량행위이지만, 허가는 원칙적으로 기속행위로 해석된다.

3. 대리

(1) 개념

- 대리는 법령상 특정인이 행해야 할 법적 행위를 그 의무자가 이행하지 않을 때, 행정청이 법정 대리인의 지위에서 그 의무자를 대신하여 행위를 하는 행정작용이다. 대리행위의 법적 효과는 행정청이 아닌 본인(원래 의무자)에게 귀속되며, 그 근거가 공법에 있고 공익을 목적으로 한다는 점에서 사법상의 대리와의 구별된다.

(2) 구별 개념

- 대리는 행정청이 의무 불이행 시 사실 행위를 강제적으로 대신 실현하는 대집행과 구별된다. 대집행은 주로 의무의 이행 그 자체를 목적으로 하는 강제 집행의 일종인 반면, 대리는 국민이 행해야 할 법률행위를 행정청이 대신하는 행위라는 점에서 차이가 있다.

4. 인가-제3자를 위한 행위

(1) 인가의 의의

- 인가란 사인이 행한 법률행위(주된 행위)를 행정청이 보충하여 그 법률적 효력을 완성시켜 주는 행정행위를 말한다. 인가는 주된 행위의 효력을 보충하는 역할을 하며, 행정청의 인가가 있어야 비로소 사인의 행위가 유효하게 된다. 인가는 그 본질상 주된 행위의 상대방인 제3자에게 영향을 미칠 가능성이 크다.

(2) 인가의 대상

- 인가의 대상은 사인의 법률행위이다. 행정청의 행위를 보충하는 것은 인가에 해당하지 않는다. 예컨대 학교 법인의 정관 변경이나 조합 설립 행위 등이 인가의 대상이 된다.

(3) 인가의 형식·상대방 및 출원

- 인가도 국민의 법률관계에 영향을 미치므로 문서로 행해지는 것이 일반적이다. 인가의 상대방은 인가를 신청한 사인(주된 행위의 당사자)이다. 인가는 사인의 신청에 의해 이루어지는 것이 원칙이다.

(4) 수정인가의 가부

- 수정인가란 행정청이 사인이 신청한 내용과 다르게 일부를 수정하여 인가하는 것을 말한다. 인가는 주된 행위의 효력을 보충하는 데 그치므로, 행정청이 사인이 신청한 내용을 임의로 수정하여 인가할 수 없다는 것이 판례 및 통설의 입장이다. 수정인가를 하려면 행정청은 인가를 거부하고 사인에게 수정된 내용으로 재신청하도록 요구해야 한다.

(5) 인가의 효과

- 인가는 주된 행위의 효력을 완성시킨다. 인가가 있어야 비로소 주된 행위가 유효하게 되며, 인가가 없는 주된 행위는 원칙적으로 무효이다. 그러나 인가는 주된 행위를 보충하는 행위일 뿐, 인가 그 자체가 주된 행위의 위법성까지 치유하는 것은 아니다.

(6) 관련 판례

- 쟁송 대상에 관하여 판례는 인가 자체의 위법성(인가 요건 미비)을 다투는 경우, 인가 처분이 항고소송의 대상이 된다고 본다. 그러나 주된 행위(조합 설립 행위)의 하자 다투는 경우, 이는 사법상의 법률관계에 관한 문제이므로 민사소송 또는 당사자소송으로 다투어야 하며, 인가 처분의 취소를 구하는 취소소송은 원칙적으로 적법하지 않다고 판단한다.

(7) 허가·특허·인가 비교

- 세 행위는 모두 법률행위적 행정행위이지만, 법적 효과가 다르다. 허가는 법적 금지를 해제하여 국민의 자유를 회복시키는 데 그치고 원칙적으로 기속행위이다. 특허는 새로운 공권을 설정하는 행위로 원칙적으로 재량행위이다. 반면, 인가는 사인의 행위를 보충하여 그 효력을 완성시키는 행위이다. 이러한 면에서 그 법적 성질이 확연히 구별된다. 인가는 법률이 정한 바에 따라 기속행위일 수도, 재량행위일 수도 있다.

IV 준법률행위적 행정행위

1. 의의

- 준법률행위적 행정행위란 행정청의 판단, 인식, 통지 등 정신 작용의 표시에 대하여 법률이 그 자체로 법적 효과를 부여하는 행정행위를 말한다. 이는 행정청의 의사 내용대로 법적 효과가 발생하는 법률행위적 행정행위와 구별된다. 준법률행위적 행정행위의 효력은 행정청의 의사와 관계없이 법규가 직접 규정하는 바에 따라 발생하며, 주로 공증, 통지, 수리, 확인 네 가지 유형으로 분류된다.

2. 공증

(1) 공증의 개념

- 공증이란 행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존재 여부에 대하여 공적인 권위로서 증명하는 행위를 말한다. 공증은 증명 행위 그 자체에 의해 법적 효과가 발생한다.

(2) 공증의 성질 및 형식

- 공증은 행정청의 판단이 아닌 인식의 표시로서, 그 자체가 법적 안정성을 확보하는 기능을 한다. 공증은 주로 문서의 형식으로 이루어진다.

(3) 공증의 종류

- 공증의 대표적인 예로는 행정청이 사실 관계를 증명하는 등기, 등록, 공증 등이 있다. 특히, 부동산등기법상의 등기는 물건 변동의 효력 요건 또는 대항 요건으로서 중요한 법적 효과를 발생시킨다. 또한, 행정청이 발급하는 각종 증명서나 확인서 역시 공증의 성격을 가진다.

(4) 공증의 효과

- 공증은 증명된 사실이나 법률관계에 대하여 추정적 공신력을 발생시킨다. 즉, 공증된 내용이 진실인 것으로 추정되어 거래의 안전을 도모하는 효력을 갖는다. 그러나 공증된 내용이 실제와 다르다면 이해관계인은 그 내용을 다툴 수 있다.

(5) 공증의 행정행위성(처분성)

- 공증은 특정 사실을 증명하는 행위에 불과하므로, 그 자체로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하지 않는 한 원칙적으로 처분성이 부정된다. 따라서 공증 행위의 위법성을 다투기 위한 취소소송은 원칙적으로 인정되지 않는다. 다만, 공증이 특정인의 법률상 지위를 결정하거나 특정 권리·의무의 성립 요건이 되는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 여지가 있다.

3. 통지

(1) 통지의 개념

- 통지란 행정청이 특정인에게 특정 사실 또는 의사를 알리는 행위이다. 통지는 행정청의 의사 표시를 외부에 전달하는 역할을 한다.

(2) 구별 개념

- 통지는 그 성격상 법률행위적 행정행위의 효력 발생 요건인 도달과 구별되어야 한다. 통지는 그 자체가 법적 효과를 발생시키는 준법률행위적 행정행위이거나, 또는 단순히 사실 행위로서 존재하는 경우가 있다. 또한, 통지는 행정청이 특정 법률관계를 확정하는 확인 행위와도 구별된다.

(3) 통지의 종류

① 사실의 통지

- 객관적인 사실을 알리는 행위(도로 폐쇄 결정의 고시)

② 의사의 통지

- 행정청이 가질 의사를 알리는 행위(대집행 계고 통지) 계고 통지는 국민에게 철거 의무의 이행을 촉구하고, 불이행 시 강제집행을 하겠다는 의사를 알리는 통지로서, 그 자체가 법률효과를 발생시키므로 처분성이 인정된다는 것이 판례의 태도이다.

(4) 통지의 효과

- 통지의 효과는 법률에 따라 다양하다. 통지는 특정 법률 효과의 발생 시점을 정하거나, 법률상 의무 이행의 시한을 알리는 효력을 가질 수 있다. 특히, 계고 통지와 같이 그 내용 자체가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 통지는 처분성이 인정되어 항고소송의 대상이 된다.

4. 수리

(1) 수리의 개념

- 수리란 행정청이 국민이 행한 일정한 공법적 행위(신고 또는 신청)를 받아들여 법률 효과를 완성시키는 행위를 말한다. 여기서 수리는 단순한 접수 행위와 구별되며, 법률적 의미를 가지는 경우에 한하여 준법률행위적 행정행위로 본다.

(2) 구별 개념

- 수리는 행정청의 의사 표시 내용대로 효력이 발생하는 허가와 구별된다. 수리는 행정청의 의사보다는 법규가 정한 바에 따라 효력이 발생하며, 행정요건적 신고의 경우 그 법적 성질이 중요하게 다루어진다.

(3) 수리의 성질

- 수리는 국민의 행위(신고 등)를 전제로 하며, 그 행위의 효력을 확인·보충하여 법률 효과를 완성시키는 확인적 성격을 가진다.

(4) 수리의 효과

- 수리의 효과는 국민의 공법상 신고나 신청의 법적 효력을 발생시키는 것이다.

① 행정요건적 신고의 수리

- 수리 행위가 있어야 비로소 신고의 법적 효과가 발생하며, 수리 거부하는 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 거부처분으로 취소소송의 대상이 된다.

② 자기완결적 신고의 수리

- 수리는 단순한 접수 사실 행위로서 원칙적으로 처분성이 부정되나, 판례는 예외적으로 수리 거부로 인해 법적 불안정성이 야기될 경우 처분성을 인정하여 국민의 권리 구제를 도모하기도 한다.

5. 확인

(1) 확인의 의의

- 확인이란 행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존부나 정당성에 대하여 공적인 권위로서 판단하고 이를 확정하는 행정행위를 말한다. 확인은 불확정한 법률 상태를 확정하여 법적 안정성을 기하는 것을 목적으로 한다.

(2) 확인의 종류

① 사실의 확인

- 특정 사실의 존재를 확정(토지 대장상의 지목 확인)

② 법률관계의 확인

- 특정 법률관계의 존부나 내용을 확정(당선인 결정, 발명 특허, 출생 신고의 수리)

(3) 확인의 형식

- 확인은 주로 문서의 형식으로 이루어지며, 이해관계인에게 통지된다.

(4) 확인의 효과

- 확인은 법률관계를 확정하는 공정력과 불가쟁력을 가진다. 확정된 내용은 그 후의 법률관계에 구속력을 미치며, 특히 특허와 같이 새로운 권리를 설정하는 행위는 아니지만, 기존 법률관계의 불확실성을 제거하여 법적 안정성을 높이는 결정적인 효과를 가진다.

V. 결론

- 법률적 행정행위의 명령적 행정행위는 국민의 자유와 의무를 직접적으로 규율하는 행정작용의 핵심이며, 허가는 자유를 회복시키고, 하명은 의무를 부과하며, 면제는 의무를 해제한다는 점에서 각각의 법적 성질이 구별된다. 이러한 명령적 행정행위는 대부분 취소소송의 대상인 처분에 해당하므로, 행정쟁송법에서는 그 요건, 효과, 위법성 판단 기준을 명확히 이해하는 것이 중요하다. 법률적 행정행위의 형성적 행정행위인 특허, 대리, 인가는 행정청의 적극적 행위로 국민의 법적 지위를 새롭게 구축하거나 타인의 행위를 완성시키는 기능을 한다. 특히, 특허와 인가는 그 법적 성질과 쟁송 대상에서 중요한 차이를 보이므로, 행정쟁송법상 인가 처분과 주된 행위의 하자를 분리하여 판단하는 법리를 정확히 이해하는 것이 핵심이다. 준법률행위적 행정행위는 행정청의 의사보다는 법규의 힘에 의해 법적 효과가 발생하는 행위로서, 공증, 통지, 수리, 확인의 네 가지 유형으로 분류된다. 이 중 통지와 수리는 특정 유형(계고, 행정요건적 신고 수리)에서 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미쳐 처분성이 인정되는 경우가 많고, 확인은 법률관계를 확정하여 가장 강한 효력을 가지므로 쟁송법상 그 구별과 처분성 여부의 판단이 중요한 쟁점이 된다.